

1502649-34.2022.8.26.0472

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: VALDEMAR BRAGHETO JUNQUEIRA

Comarca: Porto Ferreira

Foro: Foro de Porto Ferreira

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 04/10/2022

... recebimento de prévia informação de tráfico e imediata fuga do increpado ao avistar os agentes públicos, a quantidade e variedade de entorpecentes, bem como a forma de disposição fracionada e embalada demonstram, com segurança, que ele tinha trazia consigo os entorpecentes com a finalidade de tráfico. Tem-se, ainda, que o denunciado praticou a traficância nas imediações da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Porto Ferreira

Foro de Porto Ferreira

2ª Vara

Rua Dr. Carlindo Valeriani, 525, . - Centro

CEP: 13660-017 - Porto Ferreira - SP

Telefone: (19) 3581-2201 - E-mail: portoferr2@tjsp.jus.br

1502649-34.2022.8.26.0472 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1502649-34.2022.8.26.0472

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

ANTONIO EDSON ESTEVES DOS SANTOS

Vistos.

O representante do Ministério Público ingressou em juízo pedindo a condenação de ANTONIO EDSON ESTEVES DOS SANTOS, já qualificado nos autos, como incurso no topo do artigo 33 c.c. art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06 afirmando que em 23 de fevereiro de 2022, por volta de 08h, na quadra poliesportiva situada na rua José Américo da Silva, Jardim Aníbal, nesta cidade e comarca de Porto Ferreira, trazia consigo, 10 porções de "cocaína" com peso bruto de 13,0 gramas, 11 porções de "maconha" com peso bruto de 13,0 gramas e 05 porções de "crack" com peso bruto de 1,0 grama.

Segundo se apurou no inquérito policial que embasou a denúncia, "guardas municipais se dirigiram ao local dos fatos, a saber, a quadra poliesportiva municipal situada na Rua José Américo da Silva, a fim de apurar a procedência de informação de que ali novamente estava ocorrendo o tráfico de entorpecentes, isso em plena luz do dia (8h da manhã) de uma quarta-feira. Todavia, assim que avistou a aproximação da viatura, o denunciado imediatamente empreendeu fuga, no que, diante da fundada suspeita de cometimento de crime em local público, foi perseguido e capturado. Realizada busca pessoal, os agentes apreenderam em poder dele as drogas acima descritas - 10 porções de "cocaína", 11 porções de "maconha" e 05 porções de "crack". Assim, as circunstâncias e o local da prisão, com o recebimento de prévia

informação de tráfico e imediata fuga do increpado ao avistar os agentes públicos, a quantidade e variedade de entorpecentes, bem como a forma de disposição fracionada e embalada demonstram, com segurança, que ele tinha trazia consigo os entorpecentes com a finalidade de tráfico. Tem-se, ainda, que o denunciado praticou a traficância nas imediações da mencionada quadra poliesportiva."

A denúncia não foi recebida por ausência de justa causa.

O representante Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito às fls. 99/107.

O Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso ministerial em acórdão de fls. 162/167 determinando o recebimento da denúncia.

Foi apresentada defesa prévia às fls. 228/245; a citação do réu encontra-se às fls. 263.

Foi realizada audiência de instrução com apresentação de alegações finais pelas partes.

Quanto ao estado de liberdade, o Tribunal de Justiça determinou, por acórdão de fls. 162/167, a prisão da pessoa imputada.

O mandado foi expedido às fls. 179/180.

Há notícia do cumprimento às fls. 185/186.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

Com a devida vênia ao respeitável acórdão, transcorrida a instrução, é o caso de concluir pela absolvição em razão da ilicitude da prova colhida.

A decisão que relaxou a flagrante assim constou:

Está-se a analisar a legalidade da prisão e o estado de liberdade da pessoa de ANTONIO EDSON ESTEVES DOS SANTOS.

A Constituição garante a intimidade de todos, bem como o direito à livre locomoção (incisos X e XV do art. 5º da Constituição).

As forças policiais tem o dever constitucional de preservar a ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio (art. 144).

Para tanto, em razão do princípio da legalidade (art. 37 da Constituição), devem atuar nos exatos limites estabelecidos pela lei (desde que esta não viole as normas constitucionais).

As guardas municipais somente podem atuar nas atividades de polícia que estejam relacionadas aos bens e serviços públicos municipais. No caso, ainda é incerto se a tal quadra poliesportiva enquadra-se nessa categoria, razão pela qual suspende-se um juízo mais profundo sobre tal circunstância.

Os guardas municipais apontaram como justificativa para a busca pessoal denúncia anônima e fuga da pessoa imputada.

No entanto, o STJ, tribunal responsável pela uniformização da aplicação do direito processual penal no Brasil (art. 22, inciso I, c.c. art. 105, inciso III, ambos da Constituição), tem entendido que denúncias anônimas e apresentação de nervosismo ou fuga por parte da pessoa imputada não constituem "fundadas suspeitas" a ponto de legitimar a diligência invasiva.

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA ILÍCITA. REVISTA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. ILEGALIDADE. OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO.

1. Considera-se ilícita a revista pessoal realizada sem a existência da necessária justa causa para a efetivação da medida invasiva, nos termos do art. § 2º do art. 240 do CPP, bem como a prova derivada da busca pessoal.

2. Se não havia fundadas suspeitas para a realização de busca pessoal no acusado, não há como se admitir que a mera constatação de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida. Assim, o fato de o acusado se amoldar ao perfil descrito em denúncia anônima e ter empreendido fuga ante a tentativa de abordagem dos policiais militares, não justifica, por si só, a invasão da sua

privacidade, haja vista a necessidade de que a suspeita esteja fundada em elementos concretos que indiquem, objetivamente, a ocorrência de crime no momento da abordagem, enquadrando-se, assim, na excepcionalidade da revista pessoal.

3. Habeas corpus concedido para reconhecer a nulidade das provas obtidas a partir da busca pessoal realizada, bem como as delas derivadas, anulando-se a sentença para que outra seja prolatada, com base nos elementos probatórios remanescentes. HC 625819/SC, rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 23/02/2021, DJe 26/02/2021.

Obviamente, o encontro posterior do bem de origem ilícita não torna válida a diligência.

É sempre bom lembrar a decisão do STF por ocasião do Tema 280 da Repercussão Geral (RE 603616, rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, publicado em 10/05/2016) quando, em matéria absolutamente análoga (busca domiciliar sem mandado judicial), decidiu que não será a constatação de situação de flagrância, posterior à diligência, que justificará a medida, devendo os agentes estatais demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (em nosso caso, "suspeitas") para a medida.

Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral.

2. Inviolabilidade de domicílio - art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protraí no tempo.

3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos - flagrante delito, desastre ou para prestar socorro - a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia.

4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5º, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal.

5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida.

6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados.

7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.

Não diverge o STJ (sem grifos no original).

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. REVISTA PESSOAL E INGRESSO DE POLICIAIS NO DOMICÍLIO DO ACUSADO. FUNDADAS RAZÕES. INEXISTÊNCIA. ILICITUDE DOS ELEMENTOS DE

INFORMAÇÃO OBTIDOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.

1. Esta Corte Superior tem entendido, quanto ao ingresso forçado em domicílio, que não é suficiente apenas a ocorrência de crime permanente, sendo necessárias fundadas razões de que um delito está sendo cometido, para assim justificar a entrada na residência do agente, ou ainda, autorização para que os policiais entrem no domicílio.
2. Também há a compreensão neste Superior Tribunal de que se não havia fundadas suspeitas para a realização de busca pessoal no acusado, não há como se admitir que a mera constatação de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida.
3. No caso concreto, o contexto fático que antecedeu a providência tomada pelos policiais não indicam a existência de fundada suspeita de que o réu estivesse praticando qualquer delito no momento de sua abordagem, as buscas foram motivadas no "nervosismo" apresentado pelo acusado. Não ficou consignado em sentença nem no acórdão impugnado que os policiais haviam presenciado o paciente vendendo entorpecentes ou mesmo praticando qualquer outro delito que justificasse a abordagem pessoal.
4. Ordem concedida para, reconhecendo a nulidade das provas obtidas ilicitamente, bem como as delas derivadas, absolver o paciente com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal.
HC 659689/DF, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/06/2021, DJe 18/06/2021.

Como o art. 312 do Código de Processo Penal exige como requisito da prisão preventiva a prova da existência do crime e tendo a prova da suposta infração penal sido obtida por meio ilícito, o que não é admitido conforme clara determinação constitucional (inciso LVI do art. 5º), impossível a imposição da cautelar mais gravosa.

Ante o exposto, nos termos do inciso LXV da Constituição e do inciso I do art. 310 do Código de Processo Penal, declaro o flagrante ilegal, determinando o imediato relaxamento da prisão.

Expeça-se o respectivo alvará de soltura clausulado.

A decisão que não recebeu a denúncia assim estava fundamentada:

ANTONIO EDSON ESTEVES DOS SANTOS foi flagrado, nesta comarca, segundo comunicação da autoridade policial, praticando o delito de tráfico, trazendo consigo 10 porções de "cocaína" com peso bruto de 13,0 gramas, 11 porções de "maconha" com peso bruto de 13,0 gramas e 05 porções de "crack" com peso bruto de 1,0 grama.

O flagrante foi declarado ilegal e determinado o imediato relaxamento da prisão, nos termos do inciso LXV, do artigo 5º. da Constituição Federal e do inciso I do art. 310 do Código de Processo Penal (cf decisão de fls. 43/46).

Encerradas as diligências policiais, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de Antonio Edson Esteves dos Santos como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e requereu a prisão preventiva (fls. 74/77).

Segundo consta da inicial,

"Segundo foi apurado, guardas municipais se dirigiram ao local dos fatos, a saber, a quadra poliesportiva municipal situada na Rua José Américo da Silva, a fim de apurar a procedência de informação de que ali novamente estava ocorrendo o tráfico de entorpecentes, isso em plena luz do dia (8h da manhã) de uma quarta-feira. Todavia, assim que avistou a aproximação da viatura, o denunciado imediatamente empreendeu fuga, no que, diante da fundada suspeita de cometimento de crime em local público, foi perseguido e capturado.

Realizada busca pessoal, os agentes apreenderam em poder dele as drogas acima descritas - 10 porções de "cocaína", 11 porções de "maconha" e 05 porções de "crack".

Assim, as circunstâncias e o local da prisão, com o recebimento de prévia informação de tráfico e imediata fuga do inculpado ao avistar os agentes públicos,

a quantidade e variedade de entorpecentes, bem como a forma de disposição fracionada e embalada demonstram, com segurança, que ele tinha trazia consigo os entorpecentes com a finalidade de tráfico. Tem-se, ainda, que o denunciado praticou a traficância nas imediações da mencionada quadra poliesportiva.".

É caso de rejeição da denúncia por faltar justa causa para o exercício da ação penal.

Constou da decisão dada quando da análise do flagrante:

(...)

Lendo a peça ministerial, com a devida vênia ao representante do Ministério Público, anoto dois pontos de nulidades insuperáveis neste estágio da persecução penal.

(1) As razões alegadas pelos guardas municipais não constituem justa causa para a busca pessoal.

Afirmou o GCM Caramori:

Que nesta data durante patrulhamento de rotina efetuou diligência para apurar denúncia versando sobre tráfico de drogas na Quadra Poliesportiva localizada no bairro Jardim Anibal. Esclarece, que se dirigiram até o local onde encontraram o indivíduo posteriormente identificado como Antonio Edson Esteves dos Santos, o qual empreendeu fuga ao avistar a viatura.

Afirmou o GCM Oliveira:

Que nesta data durante patrulhamento de rotina, com o colega de guarda ora condutor, quando efetuaram diligência para apurar denúncia recorrente acerca da venda de drogas na quadra Poliesportiva do bairro Jardim Anibal. Relata, que, no local avistaram um indivíduo em atitude suspeita, pois ao notar a aproximação da viatura fugiu, sendo perseguido e capturado.

Vê-se, a partir das versões de ambos que a diligência baseou-se em denúncia anônima e a atitude suspeita consistiu tão somente na fuga da pessoa imputada.

Inicialmente, sobre a denúncia anônima.

Tal argumento não tem sido aceito pela jurisprudência. Isso pode ser remontado ao item 4 do Tema 280 da Repercussão Geral (RE 603616, rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, publicado em 10/05/2016) (aplicado por analogia):

(...) a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias (...)

Ou seja, para que os pressupostos da busca domiciliar e pessoal sem mandados judiciais seja válida, é necessário que os motivos alegados sejam "sindicáveis", isto é, passíveis de controle por parte da defesa.

Ora, qual defesa efetivamente cabe contra argumentos tais como "denúncia anônima" ou "nervosismo"?

Não se trata de colocar sob dúvida a palavra do policial (guarda municipal, no caso), como a posição mais açodada leva a concluir. Trata-se tão somente de estabelecer um padrão pelo qual seja possível o controle da atividade policial, impedindo que tão nobre e essencial atividade seja confundida com o arbítrio.

Ressalto também que, nos termos do voto do Exmo. Ministro Gilmar Mendes, expressamente o rechaço a denúncias anônimas e informações de inteligência policial como justa causa para diligências invasivas:

Por outro lado, provas ilícitas, informações de inteligência policial – denúncias anônimas, afirmações de “informantes policiais” (pessoas ligadas ao crime que repassam informações aos policiais, mediante compromisso de não serem identificadas), por exemplo – e, em geral, elementos que não têm força probatória em juízo não servem para demonstrar a justa causa.

Aliás, é como o STJ (tribunal responsável pela uniformização do direito processual penal no país conforme art. 105, inciso III, c.c. art. 22, inciso I, ambos da Constituição) recentemente se manifestou (grifos nossos):

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. DENÚNCIA ANÔNIMA. FUGA PARA INTERIOR DA RESIDÊNCIA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. ILICITUDE DAS PROVAS. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. JUSTA CAUSA NÃO VERIFICADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.

1. Considera-se ilícita a busca pessoal e domiciliar pessoal executadas por autoridade policial sem a existência da necessária justa causa para a efetivação da medida invasiva, com base apenas em denúncia anônima (art. 240, § 2º- CPP), bem como a prova derivada da busca pessoal.

2. Tendo a busca pessoal ocorrido apenas com base em parâmetros subjetivos dos agentes policiais (nervosismo ante a presença da autoridade policial e ingresso no interior do imóvel), sem a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida invasiva (ingresso no domicílio, sem ordem judicial), deve ser reconhecida a ilegalidade por ilicitude da prova, bem como das provas dela derivadas, nos termos do art. 157, caput e § 1º, do CPP.

3. Habeas corpus concedido para declarar ilegal a apreensão da droga e, consequentemente, trancar a da ação penal n. 5014975-62.2021.8.24.0033 (art. 386, II - CPP), determinando a restituição da liberdade dos pacientes, se por outro motivo não estiverem presos.

HC 687342/SC, rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, julgado em 05/10/2021, DJe 11/10/2021.

A demonstração de nervosismo ou a fuga da pessoa imputada também não configuram a fundada suspeita qualificada, ou seja, de que se esteja na posse de armas ou objetos que constituam corpo de delito de infrações penais (art. 244 do Código de Processo Penal).

O Brasil é signatário da CADH, sendo a Corte IDH responsável pela sua interpretação autêntica, conforme a própria Convenção. Desnecessário aprofundar no mérito do recente Prieto & Tumbeiro vs. Argentina (entre outros pontos, a Corte IDH entendeu que a detenção baseada em alegado "nervosismo" por parte dos policiais está sujeita a uma subjetividade tal que comporta um grau de arbitrariedade que é incompatível com a Convenção), sendo a confissão de culpa do estado argentino (o que afasta o argumento fácil de que o controle da atividade policial não pode ser feito em um país como o Brasil), por si só, suficiente (grifos nossos):

26. En su reconocimiento de responsabilidad internacional, suscrito el 4 de marzo de 2020, el Estado aceptó la totalidad de las conclusiones establecidas por la Comisión en su Informe de Fondo, lo cual incluye las concernientes a que las detenciones de los señores Fernández Prieto y Tumbeiro se enmarcaron en un contexto general de detenciones practicadas sin orden judicial ni supuestos de flagrancia en Argentina. En el mismo orden, en su escrito de alegatos finales de 18 de junio de 2020, el Estado reconoció que este “caso constituye un emblema de lo que se conoció en nuestro país, durante la década del 90, como el 'olfato policial', que implicaba actuaciones policiales descontroladas, incentivadas por políticas de seguridad pública basadas en operativos de prevención discrecionales, sin investigación ni inteligencia previa, y por ello, profundamente ineficientes”. Asimismo, el Estado puntualizó que “este tipo de prácticas policiales fueron promovidas por políticas de seguridad que se definían bajo el paradigma de la llamada 'guerra contra las drogas' y que, además, resultaban amparadas por un inadecuado o inexistente control judicial”

Vê-se, assim, que a diligência invasiva calçou-se apenas nas percepções subjetivas dos agentes de segurança, quando, em verdade, a lei exige uma suspeita fundada, qualificada. A lei exige "fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito".

É necessário que o agente de segurança aponte uma circunstância objetiva que o levou a antever com considerável probabilidade que a pessoa-alvo estivesse na posse de arma ou objetos que constituam corpo de delito. É necessário que o agente de segurança decline do que suspeitava (se era a posse de arma ou de outro objeto - sendo necessário citar este outro objeto).

O nervosismo, por ser extremamente subjetivo, não é justificativa aceita; o fato de tão só estar em local conhecido como ponto de tráfico, tampouco, exigindo, no mínimo, que o agente de segurança, p. ex., notasse uma presença excessivamente prolongada da pessoa imputada no local, uma posição de venda (ou de divisão de tarefas na venda) etc. Ou seja, circunstâncias compatíveis com a traficância que permitissem legitimamente inferir a probabilidade desta pessoa estar na posse de drogas. Sem estas exigências, seria lícita qualquer busca pessoal, p. ex., nos moradores da referida rua que estivessem se dirigindo às suas casas, o que é absolutamente incompatível com a proteção constitucional da intimidade.

No caso, os agentes de segurança envolvidos não disseram qual era essa "atitude suspeita", se a pessoa imputada estava pelo local havia horas, se foi vista fazendo gestos compatíveis com a venda em ponto de venda de drogas etc. Nada. Apenas disseram que a pessoa imputada demonstrou nervosismo e fugiu.

Ora, se o padrão exigido pela lei (art. 244 do Código de Processo Penal) para busca pessoal sem mandado é justamente a "fundada suspeita", aceitar como justificativa para a diligência invasiva a tão só declinação pelo agente de segurança pública de termo idêntico ou extremamente similar ("atitude suspeita") implica abdicar de qualquer controle da atividade policial.

(2) Os guardas municipais não encontraram o agente em flagrante delito.

Dando o devido respeito ao texto constitucional, as guardas municipais tem por função proteção de bens, serviços e instalações dos municípios (§8º do art. 144). Seus agentes tem, enquanto "qualquer do povo", a faculdade de dar voz de prisão quando encontrarem alguém em flagrante delito (art. 301 do Código de Processo Penal).

Mas não possuem qualquer atribuição para proceder a diligências invasivas que levem ao desvendamento da infração.

O art. 37 da Constituição impõe a toda a administração o respeito ao princípio da legalidade, segundo o qual a administração só pode fazer aquilo que está previsto em lei. Aliás, para as guardas municipais esta exigência está expressa na parte final do §8º do art. 144.

Eis o que dispõe a lei complementar local de n.º 179, de 28 de novembro de 2017, com redação praticamente idêntica ao texto da Lei (federal) 13.022/2014:

CAPÍTULO II

DOS PRINCÍPIOS BÁSICOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL COMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES

Art. 3º São princípios, básicos, da Guarda Civil Municipal de Porto Ferreira aqueles elencados na Lei Federal nº 13.022/14.

I - proteção dos direitos humanos fundamentais, do exercício da cidadania e das liberdades públicas;

II - preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das perdas;

III - patrulhamento preventivo;

IV - compromisso com a evolução social da comunidade; e

V - uso progressivo da força.

VI - compromisso com os princípios que regem a administração pública e respeito ao Estado Democrático de Direito.

Art. 4º É competência geral da Guarda Civil Municipal de Porto Ferreira a proteção

dos bens, serviços, logradouros públicos e instalações municipais e proteção às pessoas em todo Município, nos termos do § 8º, do art. 144, da Constituição Federal.

Parágrafo único. Os bens mencionados no caput abrangem os de uso comum, os de uso especial e os dominiais.

Art. 5º São competências, específicas, da Guarda Civil Municipal; respeitadas as competências dos órgãos Federais e Estaduais:

I - zelar pelos bens, equipamentos e prédios públicos do Município;

II - prevenir e inibir, pela presença e vigilância, bem como coibir, infrações penais ou administrativas e atos infracionais que atentem contra os bens, serviços e instalações municipais;

III - atuar, preventiva e permanentemente, no território do Município, para a proteção sistêmica da população que utiliza os bens, serviços e instalações municipais;

IV - colaborar, de forma integrada com os órgãos de segurança pública, em ações conjuntas que contribuam com a paz social;

V - colaborar com a pacificação de conflitos que seus integrantes presenciarem, atentando para o respeito aos direitos fundamentais das pessoas;

VI - exercer nas vias e logradouros municipais a fiscalização de trânsito, lavrar autuações e aplicar medidas administrativas, pelas infrações de circulação, parada e estacionamento, nos termos do art. 24 da Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro);

VII - proteger o patrimônio ecológico, histórico, cultural, arquitetônico e ambiental do Município, inclusive adotando medidas educativas e preventivas;

VIII - cooperar com os demais órgãos de defesa civil em suas atividades;

IX - interagir com a sociedade civil para discussão de soluções de problemas e projetos locais voltados à melhoria das condições de segurança da comunidade;

X - estabelecer parcerias com os órgãos estaduais e da União, por meio da celebração de convênios, com vistas ao desenvolvimento de ações preventivas integradas;

XI - articular-se com os órgãos municipais de políticas sociais, visando à adoção de ações interdisciplinares de segurança no Município;

XII - integrar-se com os demais órgãos de poder de polícia administrativa, visando contribuir para a normatização e a fiscalização das posturas e ordenamento urbano municipal;

XIII - garantir o atendimento de ocorrências emergenciais, ou prestá-lo direta e imediatamente quando deparar-se com elas;

XIV - encaminhar ao delegado de polícia, diante de flagrante delito, o autor da infração, preservando o local do crime, quando possível e sempre que necessário;

XV - contribuir no estudo de impacto na segurança local, conforme Plano Diretor Municipal, por ocasião da construção de empreendimentos de grande porte;

XVI - desenvolver ações de prevenção primária à violência, isoladamente ou em conjunto com os demais órgãos da própria municipalidade, ou das esferas estadual e federal;

XVII - auxiliar na segurança de grandes eventos e na proteção de autoridades e dignitários;

XVIII - atuar mediante ações preventivas na segurança escolar, zelando pelo entorno e participando de ações educativas com o corpo discente e docente das unidades de ensino municipal, de forma a colaborar com a implantação da cultura de paz na comunidade local.

Parágrafo único. No exercício de suas competências, a Guarda Civil Municipal poderá colaborar ou atuar conjuntamente com órgãos de Segurança Pública da União e do Estado, nas hipóteses previstas nos incisos XIII e XIV, deste artigo; diante do comparecimento de órgão descrito nos incisos do caput do art. 144 da Constituição Federal, deverá a Guarda Civil Municipal prestar todo o apoio à continuidade do atendimento.

Art. 6º É considerado serviço próprio do Guarda Civil Municipal, para todos os efeitos legais, inclusive a arregimentação, o exercício em cargo ou funções de

natureza de segurança, bem como os de ensino e aprendizagem nos assuntos da área de sua atuação.

Art. 7º A Guarda Civil Municipal de Porto Ferreira será custeada com recursos próprios consignados na Lei Orçamentária Anual, além de subvenções, donativos e contribuições.

Ora, partindo do princípio da legalidade, o máximo que podem os guardas municipais locais é "encaminhar ao delegado de polícia, diante de flagrante delito, o autor da infração, preservando o local do crime, quando possível e sempre que necessário". Não há qualquer autorização para diante de suspeitas de flagrantes proceder a medidas invasivas.

É preciso aqui fazer um alerta contra o argumento fácil e tentador de "quem pode o mais (prender), pode o menos (busca pessoal)". Como a decisão com base em valores abstratos exige a ponderação das consequências práticas (art. 20 do Decreto-Lei. 4.657/42), é inevitável reconhecer que a prisão é o ato de polícia máximo, razão pela qual este raciocínio é inválido por legitimar uma verdadeira equiparação das guardas municipais às polícias, conferindo a elas um poder de polícia completo. Mais. Não se pode desconsiderar a interpretação sistemática do feixe de atribuições instituído pelo constituinte no art. 144, o qual confere às polícias militares a função da patrulhamento ostensivo. De forma que as diligências preventivas, com as exceções expressas da constituição para a polícia federal (tráfico, contrabando e descaminho, policiamento marítimo, portuário e de fronteiras) e as guardas municipais (bens, serviços e instalações municipais), cabem tão somente às PMs. Vale ressaltar que é exatamente nesse sentido o entendimento do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Na Ação Direta de Inconstitucionalidade contra Lei Municipal n. 13.866/06 que fixava, dentre as atribuições da guarda municipal da capital, "exercer, no âmbito do Município de São Paulo, o policiamento preventivo e comunitário, promovendo a mediação de conflitos e o respeito aos direitos fundamentais dos cidadãos", assim entendeu o órgão máximo do tribunal. Confira-se a ementa:

Ação Direta de Inconstitucionalidade – art. 1º, inc. I da Lei n. 13.866/2004, do Município de São Paulo, que fixa atribuições da Guarda Civil Metropolitana – Art. 147 da Constituição Estadual – Proteção dos bens, serviços e instalações municipais – Matéria debatida é atinente à segurança pública – Preservação da ordem pública – Competência das polícias, no âmbito do Estado – Atividade que não pode ser exercida pelas guardas municipais – Extrapolação dos limites constitucionais – Ação direta julgada procedente, para declarar a inconstitucionalidade do dispositivo. (ADI nº 154.743-0/0-00, Rel. Des. Mauricio Ferreira Leite, j. 10/12/2008).

Trata-se, como se percebe, de entendimento consolidado:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei 5.626, de 16 de abril de 2018, do Município de Valinhos, que assegurou à Guarda Municipal a identificação como 'Polícia Municipal de Valinhos' - Alegação do Prefeito, autor da ação, de usurpação da competência privativa do Poder Executivo para disciplinar matéria sobre a organização dos serviços públicos municipais, violando a separação os poderes - VÍCIO DE INICIATIVA – Projeto apresentado por parlamentar direcionado à nova designação da Guarda Municipal - Matéria claramente de competência privativa do Chefe do Poder Executivo, conforme interpretação dos artigos 5º, 24, § 2º, item 4, 47, incisos II, XI, XIV e XIX, alínea 'a', da Constituição Bandeirante, aplicável aos Municípios por força do seu artigo 144 – Incidência, ainda, do preceito do artigo 147 da Carta Bandeirante, que reproduz o texto do artigo 144, § 8º, da CF/88, que estabelece que a guarda municipal é força de natureza civil destinada à proteção de bens, serviços e patrimônio municipal, sem se imiscuir na Segurança Pública preventiva e ostensiva de atribuição dos Estados e União – Inconstitucionalidade das guardas municipais adotarem a identificação de 'polícia', e ainda mais como 'militar', dada sua natureza civil – Não violação, por outro lado, dos preceitos orçamentários, segundo Tema 917, em repercussão Geral, no

S.T.F. - Ação julgada procedente.

TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2286983-23.2019.8.26.0000; Relator (a): Jacob Valente; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 17/06/2020; Data de Registro: 24/06/2020.

É essa também a lição da doutrina constitucionalista.

José Afonso da Silva (Comentário Contextual à Constituição, 3ª ed., São Paulo: Malheiros, 2007, p. 638/639) assevera que:

Os constituintes recusaram várias propostas no sentido de instituir alguma forma de Polícia Municipal. Com isso, os Municípios não ficaram com qualquer responsabilidade específica pela segurança pública. Ficaram com a responsabilidade por ela na medida em que, sendo entidades estatais, não podem eximir-se de ajudar os Estados no cumprimento dessa função. Contudo, não se lhes autorizou a instituição de órgão policial de segurança, e menos ainda de polícia judiciária. A Constituição apenas lhes reconheceu a faculdade de constituir Guardas Municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. Aí, certamente, está uma área que é de segurança: assegurar a incolumidade do patrimônio municipal, que envolve bens de uso comum do povo, bens de uso especial e bens patrimoniais, mas não é de polícia ostensiva, que é função da Polícia Militar. Por certo que não lhe cabe qualquer atividade de polícia judiciária e de apuração de infrações penais, que a Constituição atribui com exclusividade à Polícia Civil (art. 144, §4º), sem possibilidade de delegação às Guardas Municipais.

Pinto Ferreira (Comentários à Constituição Brasileira, v. 5, p. 246) observa que:

A Constituição de 1988 atribuiu às Guardas Municipais a tarefa de proteção aos bens, serviços e instalações do Município, conforme dispuser a lei (art. 144, § 8º), não as fazendo auxiliares da Polícia Militar nem lhes conferindo função repressiva dos crimes.

Lesley Gasparini Leite e Diógenes Gasparini (Lesley Gasparini Leite e Diógenes Gasparini, Guarda Municipal - Criação e Implantação - Constituição Federal - Constituição Estadual - Lei Orgânica do Município, in Boletim de Direito Municipal, ano IV, nº 3, pág. 203) também destacam que às guardas municipais "não lhes cabem, portanto, os serviços de polícia ostensiva, de preservação da ordem pública, de Polícia Judiciária e de apuração das infrações penais. Aliás, essas competências foram essencialmente atribuídas à Polícia Militar e à Polícia Civil".

Não diverge a melhor doutrina processual penal.

Gustavo Badaró (Processo Penal, 3ªed, 2015, p. 496), professor titular de Direito Processual Penal da USP, afirma que:

(...) há consenso no sentido de que os guardas municipais não podem realizar buscas pessoais. Por expressa previsão constitucional, cabem-lhes apenas a proteção de bens, serviços e instalações municipais, não lhes sendo atribuída nenhuma função de prevenção ou investigação de crimes.

O Desembargador Guilherme de Souza Nucci (Código de Processo Penal comentado, 2017), por sua vez, ensina:

Agentes autorizados a realizar busca pessoal: são os que possuem a função constitucional de garantir a segurança pública, preservando a ordem e a incolumidade das pessoas e do patrimônio, bem como investigar ou impedir a prática de crimes: polícia federal, polícia rodoviária federal, polícia ferroviária federal, polícias civis, polícias militares e corpos de bombeiros militares (art. 144, CF). Não possuem tal função os agentes das guardas municipais, logo, não estão autorizados a fazer busca pessoal. Naturalmente, se um flagrante ocorrer, podem prender e apreender pessoa e coisa objeto de crime, como seria permitido a qualquer do povo que o fizesse, apresentando o infrator à autoridade policial competente.

Enfim, qualquer que seja o caminho argumentativo, não podem os membros das guardas municipais proceder à qualquer diligência invasiva.

Ora, se mesmo quando diante de flagrante delito, cabe a eles somente encaminhar o autor da infração ao delegado de polícia, por qual razão poderiam proceder à busca pessoal se sequer sabiam se a pessoa acusada encontrava-se nessa situação?

Se tinham fundadas suspeitas de cometimento de crime grave (equiparado a hediondo) por parte do agente, deveriam ter, em respeito ao texto constitucional, comunicado à Polícia Militar e/ou Civil para que tomassem as medidas necessárias.

A disciplina constitucional (art. 5º, inciso LVI) é inequívoca:

são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos

Como a diligência policial foi ilícita, ela não pode ser considerada uma causa justa para fundamentar uma acusação criminal.

Como a prova da imputação do tráfico não possui outra fonte independente (art. 157, §1º, do Código de Processo Penal), é forçoso reconhecer não há condições para o exercício da ação por falta de justa causa.

Ante o exposto, REJEITO a denúncia oferecida contra ANTONIO EDSON ESTEVES DOS SANTOS, com fundamento no artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal.

A prova oral colhida em juízo em nada infirmou as razões acima expostas, sendo de rigor a manutenção da decisão pela ilicitude dos meios de obtenção de prova, agora em cognição exauriente.

Aliás, é exatamente assim que tem decidido as cortes superiores.

A Primeira Turma do STF, por maioria de 4 votos a 1, recentemente entendeu que a autorização dada pelo art. 301 do Código de Processo Penal a qualquer do povo para dar voz de prisão em flagrante não inclui o poder para realizar diligências investigativas:

Recurso extraordinário. Tráfico de drogas. Denúncia anônima. Ingresso em residência. Prisão em flagrante por guardas municipais após diligências investigativas. Nulidade da prova. Agravo regimental provido para negar provimento ao Recurso extraordinário.

1. A guarda municipal pode, e deve, prender quem se encontre em situação de flagrante delito, nos termos do art. 301 do CPP. Precedentes.

2. Hipótese em que a prisão realizada pela Guarda Municipal ultrapassou os limites próprios da prisão em flagrante. Prisão realizada, no caso, a partir de denúncia anônima, seguida de diligências investigativas e de ingresso à residência do suspeito.

3. Agravo regimental provido, com a devida vênia, para o fim de negar provimento ao recurso extraordinário, restabelecendo-se o acórdão absolutório proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo.

RE 1281774 AgR-ED-AgR/SP, rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 13/06/2022, DJe26/08/2022.

Vale o conhecimento do voto do Min. Dias Toffoli (grifos conforme original):

No tocante às competências da União, dos estados e do Distrito Federal, em matéria de segurança pública, o art. 144 da Norma Maior estabeleceu os órgãos responsáveis, vale dizer:

- “I - polícia federal;
- II - polícia rodoviária federal;
- III - polícia ferroviária federal;
- IV - polícias civis;

V - polícias militares e corpos de bombeiros militares.

VI - polícias penais federal, estaduais e distrital.”

Como visto, as guardas municipais, embora exerçam funções de proteção ao patrimônio local e de prevenção, não constam no rol do art. 144 da CF. A menção feita no § 8º se refere tão somente à faculdade atribuída aos municípios, bem como aos limites fixados pela Lei.

Todas essas instituições têm atribuições bem delimitadas. Tanto o é que a EC/2019 criou as Polícias Penais, em âmbito federal, estadual e distrital. Se o legislador constitucional não pretendesse dar a devida especificidade, poderia ter lançado mão do aparato policial já existente, ampliando-o.

Nesse contexto, entendo que as atribuições inerentes à segurança pública não se confundem, devendo ser tratadas com as peculiaridades que a atividade requer.

Sob essa perspectiva, reporto-me novamente à Lei nº 13.022/2014, que, no art. 4º, define as já citadas competências gerais e, no art. 5º, descreve as específicas.

Eis as disposições:

(...)

XIV - encaminhar ao delegado de polícia, diante de flagrante delito, o autor da infração, preservando o local do crime, quando possível e sempre que necessário;

(...)

Parágrafo único. No exercício de suas competências, a guarda municipal poderá colaborar ou atuar conjuntamente com órgãos de segurança pública da União, dos Estados e do Distrito Federal ou de congêneres de Municípios vizinhos e, nas hipóteses previstas nos incisos XIII e XIV deste artigo, diante do comparecimento de órgão descrito nos incisos do caput do art. 144 da Constituição Federal, deverá a guarda municipal prestar todo o apoio à continuidade do atendimento.”

Vê-se que a disciplina geral norteadora das atividades a serem exercidas pelas guardas municipais não contemplou a atuação investigativa própria das polícias.

À luz do regramento geral, há, em vez de atividade exclusiva, o exercício conjunto com os demais órgãos de segurança pública. Logo, ainda que a função investigativa fosse possível, essa deveria se dar em caráter auxiliar (como previsto no inciso XIV do art. 5º da Lei nº 13.022/2014, que, no art. 4º, define as já citadas competências gerais e, no art. 5º, orienta o seguinte: “encaminhar ao delegado de polícia, diante de flagrante delito, o autor da infração, preservando o local do crime, quando possível e sempre que necessário”).

(...)

Considerando a situação veiculada nos autos - a envolver diligências prévias, diga-se: a partir de denúncia anônima, a prisão se deu em razão de os guardas municipais terem ido a residência do recorrido e lá encontrado substância entorpecente, entendo pertinentes duas últimas ponderações.

Relativamente à possibilidade de a guarda civil municipal efetuar prisões em flagrante, não vislumbro ilegalidade, porquanto se qualquer do povo pode realizá-la, com mais razão devem proceder aqueles investidos da função pública (art. 5º, inciso XIV, da Lei nº 13.022/2014). Assim decidi nos autos do HC nº 200162, de minha relatoria, DJe 5/5/2021.

Por outro lado, não comungo do entendimento no sentido de que tais instituições estejam autorizadas a realizar diligências investigativas ou diligências prévias voltadas à apuração de crimes, como na situação retratada nos autos.

Já a Sexta Turma do STJ tem se orientado para a possibilidade de os guardas municipais realizarem diligências investigativas (como buscas pessoais, domiciliares ou veiculares) somente quando houver uma relação clara, direta e imediata com a tutela dos bens, serviços e instalações municipais.

Em extenso voto no REsp 1.977.119/SP (julgado em 16/08/2022, DJe 23/08/2022), o relator Min. Rogerio Schietti Cruz, citando doutrina especializada de Mariana Augusta dos Santos Zago e Guilherme Siqueira de Carvalho, aponta que a exclusão das guardas municipais do art. 144 da Constituição foi uma opção deliberada do

constituente originário, pois figuravam nesta condição inicialmente nas primeiras versões do texto (anteprojeto), demonstrando que a não limitação destas instituições é uma atitude contrária à Constituição.

Nesse sentido, conclui o Exmo. Ministro que mesmo diante de uma justa causa, não podem os guardas municipais realizar busca pessoal. A fundada suspeita para a busca pessoal é um requisito necessário (*conditio sine qua non*), mas não suficiente. A busca pessoal só será válida quando realizada por agentes públicos com atribuição para tal.

Explica a Sexta Turma que o art. 301 do Código de Processo Penal somente autoriza os guardas municipais a atuarem diante de "flagrantes visíveis de plano", quando exista uma "certeza virtual do crime" (em referência à expressão utilizada por Renato Brasileiro de Lima). O que não se verifica, segundo o citado voto, quando a situação de flagrante só se evidenciou após a realização de polícia ostensiva ou investigativa, como é o caso da busca domiciliar.

Ainda segundo o acórdão, os guardas municipais são agentes públicos com atribuição sui generis de segurança, pois apesar de não constarem do rol do topo do art. 144 da Constituição foram arrolados no seu §8º. Assim, segundo a Lei 13.675/18, atuam dentro do Sistema Único de Segurança Pública, mas nos limites de suas competências. Tais competências devem ser interpretadas restritivamente exigindo uma demonstração concreta de uma relação clara, direta e imediata da atividade da guarda com a proteção de bens, serviços e instalações dos municípios.

Esclarece o acórdão que não basta que o crime seja praticado em um bem público municipal, sendo necessário, no caso de bens e instalações, que o crime do qual se suspeita atente contra a sua integridade, e no caso dos serviços, é necessário que a conduta possa obstar a sua adequada execução.

O julgado ressalta que não cabe às guardas municipais combater a criminalidade urbana ordinária, tal como ocorre na maioria das vezes com o tráfico de drogas, sendo permitida, de outro lado, as diligências invasivas em hipótese de venda de droga dentro da sala de aula de escola municipal.

No presente caso, com a devida vênia à acusação, os guardas municipais declararam que estavam em patrulhamento de rotina e apuravam denúncia recorrente de tráfico, a indicar que estavam no combate de criminalidade urbana ordinária, como rechaça o STJ. Além disso, apontaram a existência de quadra poliesportiva municipal; entretanto, a conduta em questão não oferecia riscos à integridade dos bens e instalações municipais, nem obstava a adequada realização de um serviço público municipal (o que até poderia ocorrer diante da reclamação de algum usuário de um serviço municipal a ser ali prestado).

Segundo o relato da testemunha Caramori, a quadra do bairro não era objeto de nenhum serviço público municipal naquele momento; havia tão somente, ao lado, a realização de exame de condutores. Mas é digno de nota que, apesar da afirmação da testemunha de que os usuários do serviço visualizaram a ocorrência policial, não foram sequer ouvidos ou arrolados. Mais, conforme art. 156 da Lei 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) e a Resolução CONTRAN 358/2010, em especial seus artigos 2º e 3º, trata-se de serviço público federal delegado aos Estados e ao Distrito Federal.

Aliás, questionado, o guarda Daniel falou que, apesar das denúncias que recebiam do recorrente tráfico no local, não houve formalização destas informações junto à Polícia Civil, a qual é responsável, segundo o texto constitucional, pela investigação de crimes.

Não se verificou, assim, a relação clara, direta e imediata entre a diligência dos guardas municipais e a proteção de bens, serviços e instalações; em verdade, as circunstâncias apontam para uma atividade de policiamento ostensivo e até investigativa por parte de uma corporação que não tem competência constitucional para tal.

Veja, não se está a defender a inatividade do estado diante da tal situação. No entanto, não pode o estado, a pretexto de combater uma ilegalidade, agir em desconformidade com o ordenamento jurídico. É necessário que a atividade estatal de segurança pública seja executada com respeito ao texto constitucional.

Portanto, com a devida vênia aos entendimentos em contrário, as provas colhidas pela acusação foram obtidas por meios ilícitos, as quais são inadmissíveis nos termos do inciso LVI do art. 5º da Constituição.

Em relação ao estado de liberdade da pessoa imputada tendo a questão sido analisada pelas instâncias superiores a partir de circunstâncias de fato e de direito próximas àquelas analisadas nesta sentença, deixo de me manifestar, devendo eventuais pedidos ser direcionados a tais instâncias.

Com relação ao requerimento da defesa técnica em audiência, apesar da assunção do vício, não houve relatos por parte do réu de que estava sob efeito de drogas naquele momento.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido condenatório para ABSOLVER ANTONIO EDSON ESTEVES DOS SANTOS das acusações a ele imputadas na denúncia nos termos do inciso VII do art. 386 do Código de Processo Penal.

Nos termos do artigo 72 da Lei nº 11.343/06 e Comunicado CG 2225/18, determino a destruição de eventuais amostras de entorpecentes guardadas para contraprova.

Expeça-se certidão de honorários.

Com o trânsito em julgado, ao arquivo com as anotações de praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Porto Ferreira, 4 de outubro de 2022.

Valdemar Bragheto Junqueira - Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA